

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2015/9909

Na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/9909, realizada em 05 de setembro de 2017, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, por maioria de votos, no tocante à dosimetria da pena, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Fabrizio Dulcetti Neves a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 111.411.665, 62 (cento e onze milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), pela prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Gustavo Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Coordenação de Controle de Processos Administrativos

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/9909

Acusado: Fabrizio Dulcetti Neves

Assunto: Apurar a eventual ocorrência de infração ao disposto no inciso I da Instrução CVM nº 8/79 em razão da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

Relator: Diretor Gustavo Borba

RELATÓRIO

I. Do Objeto.

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado em 04.12.2015, pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN", ou "Acusação"), para apuração de infração supostamente praticada por Fabrizio Dulcetti Neves ("Fabrizio", ou "Acusado"), diretor responsável pela administração de carteiras (gestão) de valores da Atlântica Administração de Recursos Ltda. ("Atlântica", ou "Gestora") durante o período em que esta esteve registrada na CVM (26.07.2006 a 08.07.2013), que teria causado prejuízo de US\$ 79 milhões ao Fundo Brasil *Sovereign II* ("Fundo"), cujo cotista único era o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, em operação de investimento em títulos de dívida privados realizada em dezembro de 2011.

II. Da Origem.

2. O presente PAS originou-se a partir de fato relevante (fls. 21/22) publicado, em 04.08.2014, pela administradora do Fundo, a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. ("Administradora", ou "BNY Mellon"), no qual era informado que uma investigação realizada no Fundo (anteriormente denominado FIDEX) teria descoberto suposto pagamento de "*valor excedente de aproximadamente US\$79,000,000*" na aquisição de dois títulos de dívida privados¹.

3. O mesmo fato relevante informava que, em função da suspensão de pagamentos de títulos da dívida externa da República Argentina, seria necessário realizar provisões para perdas na carteira do Fundo, o que teria impacto negativo de 51,48% no patrimônio líquido do *Brasil Sovereign II*.

4. A SIN, dentro de sua rotina de supervisão de fundos de investimento, iniciou processo investigativo que gerou a instauração deste PAS.

III. Dos Fatos.

5. O *Brasil Sovereign II* é um fundo de investimento da classe Dívida Externa, constituído em 20.10.2006. A Atlântica foi a gestora do Fundo até 01.03.2012, quando foi substituída pela BNY Mellon, que também era sua administradora.

6. O único cotista do Fundo é o BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa, que recebe aplicações exclusivamente da POSTALIS.

7. Em razão do *default* da Argentina, em 01.08.2011 foi realizada provisão para perdas em carteira, diminuindo o patrimônio líquido do fundo de R\$384.403.322,64 para R\$186.520.058,46 (redução de 51,48%), como informado em fato relevante de 04.08.2014.

8. Dentre os ativos impactados por esse *default*, dois deles, identificados pelos códigos ISIN XS0716257539 e XS0721046760, teriam sido objeto da suposta fraude investigada no termo de acusação.

IV. Termo de Acusação (fls. 1158 a 1177).

9. Com base nas informações fornecidas pela BNY Mellon, a SIN apurou que os ativos acima listados eram "*First to Default Credit Linked Notes*", notas que pagam o valor nominal, exceto na hipótese de ocorrência de evento de crédito em pelo menos um dos títulos que lastreiam cada nota², e que possuíam as seguintes características (fls. 32-36):

- i) XS0716257539: notas lastreadas em títulos emitidos pelos governos do Brasil, da Argentina e da Venezuela, de valor nominal de US\$ 60 milhões, data da operação: 15.12.2011; data de liquidação: 20.12.2011; vencimento em 21.12.2021 e preço de emissão de US\$49.592.400,00 (82,654% do valor nominal); e
- ii) XS0721046760: notas lastreadas em títulos emitidos pelos governos do Brasil e da Argentina e da Petróleos da Venezuela S.A. ("PDVSA"), de valor nominal de R\$ 78 milhões; data da operação: 19.12.2011; data de liquidação: 22.12.2011; vencimento em 20.12.2021 e preço de emissão de US\$70.820.100,00 (90,795% do valor nominal).

10. Essas características teriam sido informadas pela Atlântica, por meio de dois *termsheets* enviados à BNY Mellon, administradora do Fundo, em 18.01.2012 (fls. 37-96).

11. Entretanto, a BNY Mellon, ao solicitar à UBS AG, Jersey Branch ("UBS AG", ou "Emissora"), emissora das notas, cópias dos referidos *termsheet*, teria recebido

documentos com informações diferentes. De acordo com os documentos obtidos, as características das notas compradas pelo Fundo seriam as seguintes (fl. 97-161 e 236-295):

- i) XS0716257539: notas lastreadas em títulos emitidos pelos governos do Brasil, da Argentina e da Venezuela, de valor nominal de US\$ 60 milhões, data de emissão: 07.12.2011; data da operação: 28.11.2011; vencimento em 21.12.2021 e preço de emissão de US\$17.340.000,00 (28,90% do valor nominal); e
- ii) XS0721046760: notas lastreadas em títulos emitidos pelos governos do Brasil e da Argentina e da Petróleos da Venezuela S.A. ("PDVSA"), de valor nominal de R\$ 78 milhões, data de emissão: 20.12.2011; data da operação: 14.12.2011 e vencimento em 20.12.2021 e preço de emissão de US\$24.024.000,00 (30,80% do valor nominal).

12. As tabelas abaixo evidenciam as diferenças mais relevantes entre as informações constantes nos *termsheets*:

Ativo XS0716257539	Data da Operação	Valor Nominal	Preço de emissão	
			% do VN ³	US\$
Informações fornecidas pela Atlântica	15.12.2011	US\$ 60 milhões	82,654	49.592.400,00
Informações fornecidas pela UBS AG	28.11.2011	US\$ 60 milhões	28,90	17.340.000,00

Ativo XS0721046760	Data da Operação	Valor Nominal	Preço de emissão	
			% do VN	US\$
Informações fornecidas pela Atlântica	19.12.2011	US\$ 78 milhões	90,795	70.820.100,00
Informações fornecidas pela UBS AG	14.12.2011	US\$ 78 milhões	30,80	24.024.000,00

13. Além disso, o regulamento do Fundo, replicando o art. 96 da ICVM nº 409/04⁴, estabelecia que seu patrimônio líquido deveria ser composto por, no mínimo, 80% de títulos representativos de dívida externa de responsabilidade da União.

14. A *BNY Mellon* teria comunicado à Atlântica, em 29.12.2010, um desenquadramento da carteira do *Brasil Sovereign*, que passou a ter 79,87% de seus ativos em títulos de dívida externa da União. Tal desenquadramento teria ocorrido de forma passiva, pela valorização superior dos ativos de crédito privado em relação aos títulos emitidos pela União, tendo a gestora argumentado que a venda de títulos de crédito privado traria prejuízos ao fundo, tendo em vista a baixa liquidez de tais títulos⁵.

15. O último mês em que a carteira teria ficado enquadrada teria sido novembro de 2010 e a participação dos títulos de dívida externa da União teria decrescido até atingir o

percentual 2,13% em dezembro de 2011, quando o Fundo teria comprado as notas emitidas pelo *UBS AG, Jersey Branch*, de que tratam o termo de acusação.

16. Antes dessa aquisição, o fundo teria vendido todos os títulos de emissão da União e adquirido, em seguida, as duas notas emitidas pelo UBS AG.

17. Ao contrário das solicitações da *BNY Mellon*⁶ (em maio e junho de 2011, fls. 314-320), de que todas as operações de crédito privado realizadas pelo fundo deveriam ser submetidas à sua aprovação prévia, as operações ora em discussão não teriam sido comunicadas à Administradora, segundo o relato desta.

18. Sobre o procedimento de liquidação das *credit linked notes*, após solicitado pela área técnica, a *BNY Mellon* informou que “as operações de aquisição das Notas do UBS foram realizadas pela Atlântica fora do Brasil”. Acrescentou ainda o seguinte:

(...) os títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União Federal que integravam a carteira do Fundo foram transitoriamente colocados, a pedido da Atlântica, em custódia junto à corretora Tillerman Securities Ltd., sediada nas Bahamas, em subcustódia do Bank of Butterfield, aguardando a realização de operação pela Atlântica, a qual, acreditávamos, nos seria submetida previamente (...)

Ao contrário do que acontece no Brasil, a liquidação de operações no exterior ocorre sem qualquer participação da administradora, bastando que haja a ordem exclusivamente da gestora. Como a Atlântica efetuou no exterior a ordem de venda dos títulos (...) e enviou os respectivos *termsheets* e as anexas boletas das operações para o *BNY Mellon DTVM* quando tais operações já haviam sido definitivamente concluídas, o *BNY Mellon DTVM* se viu impossibilitado de tomar qualquer providência para impedir, ou sustar, a sua realização. (...) o *BNY Mellon DTVM* apenas tomou conhecimento da substituição dos títulos (...) no final de janeiro de 2012 (...) (fls. 316 - g.n.)

19. Em sua manifestação, Fabrizio alegou que a Atlântica nunca teria realizado a custódia, ou qualquer tarefa que envolvesse títulos ou valores financeiros. Tais tarefas seriam executadas pela *BNY Mellon DTVM*, que poderia prestar esclarecimentos sobre esse tema.

20. Sobre o desenquadramento, o Acusado também alegou que manter o enquadramento seria uma responsabilidade da administradora, conforme o art. 65, XIII da ICVM 409/04⁷.

21. O gestor alegou ainda que, pouco antes da realização de tais operações, a POSTALIS (cotista único) havia imposto restrições à capacidade de gestão da Atlântica, retirando sua discricionariedade para tomar as decisões de investimento. “*Em virtude disto, e constatando a existência das operações discriminadas em seu ofício, as quais, de forma alguma, foram deliberadas pela Atlântica Administradora de Recursos Ltda., essa apresentou sua renúncia e deixou de ser gestora do fundo há mais de quatro anos*” (fls. 365-366).

22. Assim, alega Fabrizio, a responsabilidade pela realização desses negócios não poderia ser atribuída à Atlântica. Uma prova disso é que os títulos teriam continuado a compor a carteira do fundo mesmo após a saída da Atlântica, e, inclusive, apresentado rentabilidade elevada. Quando surgiu o risco de *default* é que “*questões (...) começaram a ser trazidas à tona*”.

23. Para a Acusação, embora Fabrizio alegue que a Atlântica nunca teria prestado serviços para o Fundo, os títulos representativos da dívida externa da União que integravam sua carteira teriam tido a sua custódia transferida para *Tillerman Securities Ltd.*, nas Bahamas, a pedido da Atlântica. Esse pedido precedeu a venda desses títulos e a aquisição das notas emitidas pelo UBS AG. As notas explicativas das demonstrações financeiras do Fundo confirmariam que a empresa das Bahamas prestava serviços de custódia para o *Brasil Foreign* (fls. 384).

24. A disparidade entre os valores apresentados pela Atlântica ao *BNY Mellon* (§0, retro) e aqueles informados pelo emissor, UBS AG (§12, retro), seriam evidências de que o Fundo pagou US\$79.048.500,00 a mais que o devido, ou seja, um sobrepreço de 191,10% (fls. 97-161 e 229-295)⁸.

25. Em correspondência de 26.03.2015 (fls. 388-389) a *PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes*, auditor do Fundo, teria informado que, diante da documentação obtida pelo *BNY Mellon*, teriam refeito seus cálculos, que agora teriam passado a indicar que “*o valor contábil desses Notes seriam (sic) materialmente inferiores aos divulgados nas demonstrações financeiras elaboradas e divulgadas pela Administradora nas referidas datas-bases*” e, portanto, teriam solicitado à Administradora⁹ que adotasse as providências cabíveis e estariam informando, nos termos do art. 25 da ICVM 308/99, que os relatórios de auditoria que acompanham as referidas demonstrações financeiras não mais refletem a sua opinião.

26. A Acusação menciona, com base em precedentes, que “*para tipificar uma operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários se faz necessário comprovar a existência dos seguintes elementos: (i) ardil ou artifício; (ii) indução ou manutenção de terceiro em erro; e (iii) intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros*” (fl. 1167).

27. Ressaltou que as notas adquiridas pela Atlântica, por serem instrumentos derivativos de crédito, enquadrar-se-iam no conceito de valor mobiliário, nos termos do art. 2º, VIII, da Lei nº 6.385/76¹⁰.

28. Por ser o diretor responsável pela administração de carteiras da Atlântica, o Acusado seria a pessoa responsável pelas decisões de investimento e desinvestimento relacionadas à carteira do Fundo.

29. O ardil utilizado na prática de fraude ao mercado de valores mobiliários, segundo a acusação, teria sido apresentar à Administradora *termsheets* “falsos” em valores diferentes (muito superiores) àqueles que constavam das notas efetivamente emitidas pela UBS AG.

30. Além disso, ter-se-ia maliciosamente aproveitado, para a realização da fraude, do ambiente de negociações das notas no exterior, que acontecia sem a participação da Administradora, e desobedecido o mecanismo de controle instituído pela BNY Mellon, que

havia determinado que qualquer operação sob a gestão da Atlântica deveria ser previamente submetida à área de enquadramento da *BNY Mellon*.

31. O estratagema teria causado sérios prejuízos aos participantes da POSTALIS, posto que o fundo teria adquirido as notas por valor fraudado, com isso induzindo “em erro os milhares de trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas participantes daquele instituto de previdência” (fl. 1.170).

32. Quanto ao terceiro elemento, a intenção de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial, afirma a acusação que o Fundo desembolsou US 79.048.500,00 a mais na aquisição das notas de emissão do UBS AG, de modo que tal montante teria sido apropriado pelo Acusado (diretor responsável pela administração de recursos de terceiros) ou por terceiros em conluio com ele.

33. Assim sendo, Fabrizio teria descumprido o inciso I, na forma do inciso II, “c”, da ICVM 08/79:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;

34. Além disso, a SIN sustenta que o desenquadramento da carteira do Fundo em relação a seu regulamento e à ICVM 409/04 também seria de responsabilidade do Acusado, e não da Administradora *BNY Mellon*, que teria alertado Fabrizio sobre o desenquadramento.

35. Acrescenta que o gestor contratado (Atlântica) possuiria poderes para negociar os títulos e valores mobiliários que integram a carteira do fundo de investimento, conforme disposto no art. 56, §2º, da ICVM 409/04¹¹, não podendo o Acusado eximir-se da responsabilidade pelo desenquadramento da carteira (fls. 1.172-1.774). Também não haveria nos autos qualquer evidência de que o POSTALIS tenha influenciado na decisão das operações relatadas.

36. Outra prova de que a Atlântica seria responsável por essas transações seria um e-mail encaminhado por uma funcionária da Atlântica à BNY Mellon, em 18.01.2012 (fls. 413/417), contendo as boletas de venda dos dois títulos da dívida externa brasileira e os *termsheets* correspondentes às notas emitidas pelo UBS AG (fls. 37/96 e 162/228) e adquiridas pela gestora para o Fundo.

37. Embora a Acusação mencione a responsabilidade e a falta de diligência do Acusado em relação ao enquadramento da carteira às regras do Fundo, e mencione uma suposta infração ao art. 65, XIII, c/c o art. 57, §5º, e art. 96 da ICVM nº 409/04, tal

acusação não foi formalizada no capítulo de responsabilidades, por sugestão da PFE-CVM, que opinou no sentido de que *"a conduta mais abrangente seria aquela descrita no item I, na forma da alínea 'c' do item II da Instrução CVM nº 08/79, ao passo que as condutas absorvidas seriam aquelas descritas nos artigos 65, inciso XIII, 57, §5º, e art. 96 da ICVM nº 409/04, na medida em que estas últimas caracterizam-se como atos preparatórios e executórios da infração consumada (...) portanto, meios necessários e indissociáveis da conduta contingente"*¹² (fl. 464).

38. Dessa forma, a SIN propôs *"a responsabilização do Sr. FABRIZIO DULCETTI NEVES (...) por infração ao item I, na forma da letra 'c' do item II, da Instrução CVM nº 8, de 8.10.1979"* (fl. 1.177).

V. Da Manifestação da PFE (fls. 463-467).

39. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE¹³ ("PFE-CVM") entendeu que, além da observação descrita no parágrafo 0, estariam preenchidos os requisitos constantes dos art. 6º e art. 11, ambos da Deliberação CVM 538/08¹⁴.

40. A Procuradoria observou que a efetiva percepção da vantagem indevida não é requisito para a caracterização de operação fraudulenta, bastando *"que o agente tenha tido a intenção de obter vantagem ilícita, usando para tanto de ardil ou artifício destinado a manter terceiros em erro"* e, portanto, *"para os fins de uma efetiva atuação sancionadora da Autarquia em casos envolvendo a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, a discussão sobre se determinado valor foi efetivamente apropriado por esta ou aquela pessoa, para fins de prova da intenção do acusado de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros, conforme consta do parágrafo 54 do termo de acusação, parece de todo desnecessária"* (fl. 465)¹⁵.

41. A PFE-CVM julgou, ainda, ser necessária a comunicação à Procuradoria da República em São Paulo, tendo em vista a existência do Procedimento nº 1.34.001.006627/2012-72 (PR/SP) que envolve a suposta prática de ilícitos perpetrados no âmbito da Atlântica Administração de Recursos Ltda. (fl. 466)¹⁶.

42. Por fim, por orientação da PFE-CVM, a SIN alterou o Termo de Acusação (fls. 1.158 a 1.177) a fim de incluir as traduções juramentadas dos documentos em língua inglesa que constam nos autos. O presente relatório já reflete as alterações realizadas.

VI. Da Defesa (fls. 1.204 a 1.330).

43. Preliminarmente, o Acusado ressalta que nenhum dos documentos trazidos aos autos teria sido, em momento algum, encaminhado à CVM por seu agente emissor, tendo sido remetidos somente pela *BNY Mellon* e, por se tratarem de cópias, seriam de origem incerta e inválidos juridicamente. Além disso, a Administradora seria ré em ação judicial proposta pelo POSTALIS por ter atuado de forma semelhante à observada nesses autos na administração das carteiras em geral.

44. Por essas razões, teria sido prematura a instauração do Processo Administrativo Sancionador.

45. A tradução juramentada dos documentos não bastaria para que tivessem validade, sendo necessário também que os documentos fossem “consularizados” e tivessem o devido registro, na forma da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973¹⁷⁻¹⁸, art. 129, inciso 6º e art. 148.

46. O contrato de serviço 560-0, firmado entre a Administradora e o POSTALIS em dezembro de 2010¹⁹, seria prova de que a *BNY Mellon* teria assumido responsabilidade única, exclusiva e integral pelas operações levadas a efeito no âmbito do Fundo. Prova disso seria a ação civil nº 0266411-48.2014.8.19.0001, que tramita perante a justiça estadual do Rio de Janeiro, que teria determinado que a *BNY Mellon* depositasse fiança com intuito de precaver futura perda de ação. Anexou, também, cópia da petição inicial de ação civil proposta pelo POSTALIS contra a BNY Mellon, na qual a Administradora contaria como única ré (fls. 1295-1330).

47. Segundo a Defesa, os poderes da Atlântica estariam cassados desde maio de 2011, em virtude do recebimento de correspondências enviadas pela Administradora à Gestora que determinavam que as operações realizadas pela Atlântica estariam sujeitas à análise e aprovação pela área de Enquadramento (fls. 319-320). Assim, segundo a perspectiva do Acusado, estaria comprovado que as operações realizadas na carteira do Fundo seriam de responsabilidade da BNY Mellon.

48. Além disso, não existiriam provas para demonstrar que as referidas Operações foram realizadas pela Gestora, ou a pedido dela.

49. Para o defendente, nenhum banco minimamente responsável acataria a solicitação de transferência de custódia de uma posição da magnitude da Operação por parte de uma gestora sem poderes sem que houvesse confirmação formal do administrador e controlador dos custodiantes.

50. Seria, também, inverossímil que a *BNY Mellon*, já tendo remetido duas correspondências em que retirava os poderes de gestão da Atlântica, teria transferido parcela significativa dos ativos do Fundo para um custodiante internacional, acreditando que a gestora submeteria previamente uma eventual transação à sua prévia autorização.

51. Jamais teria existido relação direta entre o POSTALIS e a Atlântica. O POSTALIS teria contratado a *BNY Mellon* para administrar uma massa de recursos, assumindo esse dever fiduciário em relação à primeira. A Atlântica, por sua vez, teria sido contratada pela *BNY Mellon* para gerir a carteira do Fundo, o qual representaria menos de 5% dos ativos que a *BNY Mellon* administrava para o POSTALIS.

52. Ao contratar a Atlântica, a BNY Mellon não estaria se abstendo de qualquer obrigação em relação ao Fundo. Em seu entendimento, a Atlântica passaria a exercer somente as funções de gestora, que seriam, inclusive, bastante restritas. A Administradora continuaria a ter várias funções; sendo evidente, no presente caso, que ela, e não a Atlântica, teria falhado no exercício dessas funções.

53. Adicionalmente, conforme definido no contrato já mencionado firmado entre a BNY Mellon e o POSTALIS, caberia somente à BNY Mellon escolher e contratar corretoras custodiantes no Brasil e no exterior, conforme cláusulas transcritas²⁰:

"(...)cabendo à BNY Mellon as seguintes atribuições:

2.2.2. a contratação, em nome dos Fundos e do titular da Carteira Própria, da instituição prestadora de serviços qualificados de custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira ("Custodiante")

(...)

13.1. A fim de garantir a eficiência dos controles objeto desta cláusula, a CONTRATADA, ao realizar a contratação dos Gestores, fará constar expressamente dos contratos, além de outras, a obrigação dos Gestores ao atendimento das seguintes regras básicas, em benefício da gestão e do CONTRATANTE: (a) a precificação dos ativos será realizada exclusivamente pela CONTRATADA; (b) a CONTRATADA poderá recusar operações que estejam fora das práticas usuais e equitativas de mercado e que não se enquadrem na legislação, nos regulamentos dos Fundos, na política de investimento da Carteira Própria e na PI; (c) a CONTRATADA poderá vetar a realização de operações com corretoras e/ou contrapartes que não se enquadram nos critérios de risco de crédito previamente estabelecidos pela CONTRATADA; (...)"

54. Dessa forma, a Gestora se comunicaria de forma limitada com a corretora apenas após a indicação e aprovação pela Administradora. Portanto, seria obrigação da *BNY Mellon* detectar e informar qualquer mudança na composição do fundo ao cliente e à gestora, o que não teria sido feito em momento algum.

55. Quanto à custódia do Fundo, essa teria sido, assim como a conta-corrente, aberta pela *BNY Mellon* no banco Bradesco. Os custodiantes seriam pré-aprovados pelo administrador. Somente a Administradora estaria apta a movimentar essa custódia, visto que o Bradesco não reconheceria a Atlântica como apta para isso.

56. A Defesa alega que, para que o custodiante internacional aceitasse a transferência da custódia, a *BNY Mellon* deveria firmar uma série de documentos, formalidade que só poderia ser feita pela Administradora. Ambas as contas de custódia, nacional e internacional, seriam controladas pela *BNY Mellon*, em custodiante internacional. Dessa forma, a transferência do Bradesco para o custodiante internacional não teria alterado em nada a posição da Atlântica frente à questão da custódia.

57. Além disso, ressaltou que toda a movimentação de títulos deveria ser comunicada imediatamente pelo custodiante ao Fundo. Não seria verossímil, portanto, que a *BNY Mellon* ficasse sabendo das operações pela Atlântica. Nada obstante, a Defesa salientou que a Administradora teria poderes de não acatar a operação se assim o quisesse.

58. A comprovação de quem determinou a realização da alienação de títulos de dívida externa e a aquisição de títulos privados se daria com a apresentação de ordem competente, consubstanciada em boleto ou instrumento assemelhado. Contudo, não constaria dos autos qualquer documento dessa natureza firmado pela Atlântica ou por Fabrizio Dulcetti. A Atlântica e o seu diretor responsável à época teriam se oposto ferozmente à sua realização. E, na concretização da referida operação, a Atlântica teria, imediatamente, apresentado a sua renúncia à gestão.

59. A Defesa salientou, mais uma vez, que a Atlântica não teria determinado a alienação dos títulos da dívida externa, tampouco a compra dos títulos emitidos pelo UBS. A Atlântica teria aberto mão da gestão do Fundo justamente por ter discordado

dessa operação. Ainda que os títulos tivessem sido irregularmente adquiridos pela Atlântica, era função e obrigação do administrador, ou do novo gestor, livrar-se deles imediatamente, o que não ocorreu. A administradora poderia ter feito *hedge* para proteger o fundo de eventual *default* e perdas substanciais, o que não fez.

60. A *BNY Mellon* teria continuado, até meados de 2014, a contabilizar a posição e a precificar os ativos regularmente, o que teria feito o Fundo apresentar rentabilidade excepcional (R\$100.000.000,00, ou 28% de retorno).

61. No email que consta como prova de que a operação teria sido realizada pela Atlântica²¹, teria sido encaminhada uma boleta emitida em português pela própria Administradora, além de um arquivo de nome "Termsheet das NP", que não passaria das Minutas para discussão. Não seria possível comprovar a referida Operação por esses documentos, tampouco acreditar que a *BNY Mellon* tivesse contabilizado ativos de mais de U\$ 100 milhões, mediante minuta de dois *termsheets*.

62. Ainda quanto ao e-mail, por fim, a Defesa teceu os seguintes comentários: i) não haveria como se garantir que os anexos do e-mail fossem os que a *BNY Mellon* teria alegado se tratar; ii) S.B., da *BNY Mellon*, teria pedido, em outro e-mail²² para que Priscilla lhe telefonasse, levantando questionamento por parte da Defesa acerca de uma instrução que não poderia ficar registrada por escrito e que contrariaria as regras de *compliance*; iii) enquanto alguns e-mails adotaram o sistema de doze horas para informar as horas, outros tomaram como base o sistema de 24 horas, sem motivo aparente; e iv) determinado e-mail mencionaria "as boletas corretas", fato pelo qual a Defesa questionou se haveria outras boletas anteriores; e v) quem seria C. S.?

63. Além disso, não seria possível concluir com exatidão que os *termsheets* constantes nos autos (fls. 37-96 e 97-161) teriam sido de fato enviados no referido e-mail. Alega-se, inclusive, que seria bastante improvável, visto que esse tipo de arquivo é dificilmente transmitido, ou recebido, via e-mail, devido ao seu tamanho. Pondera, ainda, que seria "absolutamente incomum" que os *termsheets* fossem encaminhados por e-mail.

64. Dessa forma, seria impossível determinar qual seria o verdadeiro *termsheet*, tendo em vista a discrepância entre os *termsheets* apresentados. Ademais, não teria sido trazido à colação o real preço pelo qual as notas foram compradas, como teriam sido liquidadas e qual teria sido o fluxo dos recursos.

65. Estaria pacificado na doutrina que a responsabilidade administrativa, principalmente se tratando do exercício do Poder de Polícia, é subjetiva, visto que, dentro da Teoria Geral dos Ilícitos, vigeria o princípio do *nullum crime sine culpa*. Nesse sentido, segundo Heleno Fragoso e outros²³, inexistiria diferença ontológica entre ilícitos administrativo e penal, havendo, tão somente, diferenciação de quantidade ou de grau. Tal entendimento se estenderia também à responsabilidade civil, no âmbito da Lei 6.024/74 e do Decreto Lei nº 2.321/87. Haveria, inclusive, jurisprudência²⁴ e precedentes administrativos²⁵ consoantes a esse entendimento.

66. Portanto, seria imprescindível comprovar que o acusado agiu de forma culposa, o que não teria ocorrido no presente caso, pois não seria possível comprovar sequer que a Atlântica teria sido responsável pelas operações.

67. A Defesa reconheceu a possibilidade de utilização da prova indiciária no Direito Brasileiro, desde que os indícios sejam robustos e convergentes²⁶, o que não seria o caso, pois: i) não existiria qualquer indício de que Fabrizio Dulcetti fosse responsável pelas operações; ii) as perdas substanciais do Fundo ocorreram após a saída da Atlântica de sua gestão; iii) não haveria evidências e elementos materiais, apenas opiniões emitidas por terceiro interessado (fls. 1243).

68. Mais uma vez, reiterou-se que notas recebidas pela BNY Mellon seriam apenas minutas e não poderiam ser contabilizadas. Além disso, como administradora, a BNY Mellon estaria obrigada a reverter a operação em D-1, ou D-3; contudo, teria ficado caracterizado que a *BNY Mellon* acatou a operação e permaneceu dois anos com o papel, precificando-o e não assegurando um possível risco de *default*.

69. Por fim, solicitou abertura de prazo para interposição de provas, bem como o reconhecimento das nulidades apontadas pela Defesa, levando à nulidade do presente processo.

VII. Do Pedido de Produção de Provas (fls. 1.361 a 1.368).

70. Em petição protocolada em 10.08.2017, o Acusado apresentou uma lista de documentos que, segundo ele, caberiam à CVM, utilizando seu poder de polícia, obter junto à Administradora.

71. Tanto o pedido genérico de produção de provas quanto o peticionado posteriormente foram negados por meio de despacho por mim exarado em 14.08.2017, nos seguintes principais termos:

Como o §2º do art. 13 da Deliberação CVM nº 538/08²⁷ determina que o Acusado deve instruir sua defesa com os documentos pertinentes, não tenho dúvida em concluir que, caso não tenha acesso a tais documentos, deve o Acusado fazer requerimento, na própria defesa²⁸, especificando os documentos pretendidos, de modo a permitir a produção da prova (por meio de intimação de quem os possui)²⁹.

No caso, como já exposto, o Acusado assim não procedeu, limitando-se a fazer pedido de provas genérico em sua defesa, do que se extrai a preclusão da questão, uma vez que o pedido extemporâneo realizado após a inclusão do caso em pauta não possui aptidão para reavivar a oportunidade processual perdida.

Ademais, considerando que a inclusão do processo em pauta (D.O.U. de 01.08.2017) é incompatível com a produção de qualquer eventual prova, não há dúvida de que, nos termos do disposto no art. 22 da Deliberação CVM nº 538/08³⁰, o acusado teria prazo de cinco dias para apresentar impugnação sobre a questão da realização da prova, o que não foi observado (a petição foi protocolizada em 10.08.2017), operando-se, por conseguinte, a preclusão também por essa perspectiva, que é ora analisada para fins de argumentação.

No entanto, apesar da preclusão, a CVM sempre pode realizar a produção de prova documental que seja importante e pertinente ao caso, a fim de obter melhor elucidação das circunstâncias relacionadas ao processo.

Não é esse o caso do pedido de prova ora em análise

(...)

Quanto aos contratos supostamente celebrados pela gestora Atlântica com a *BNY Mellon* e com o Postalís (itens 4 e 5), cumpre observar que o **Acusado**, que era administrador e controlador totalitário da Atlântica desde a sua origem até a sua extinção (com 95% de participação direta e 5% indireta), teria, por razões evidentes, pleno acesso a tais supostos documentos, do que decorre a total desnecessidade dessa produção probatória.

Igualmente improcedente é o pedido de apresentação do contrato entre a *BNY Mellon* e o Postalís (item 3 do pedido), uma vez que esse contrato já se encontra nos autos (fls. 1249/1261) (...)

Quanto aos extratos mensais elaborados pela Administradora (item 2), cumpre observar que todas as informações pertinentes a esses extratos estão disponíveis no *site* da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br/>³¹), que é aberto ao público e permite o acesso a informações relativas a qualquer mês desde a constituição do fundo, razão pela qual a produção probatória requerida afigura-se completamente desnecessária³².

O último pedido (item 1) a ser analisado refere-se à “cópia dos contratos, fichas de cadastro, procurações e instrumento de concessão de poderes para movimentação de conta de custódia e cartões de assinatura havidos entre o Bradesco e o Fundo, desde sua constituição até 31.03.2012 (...)”.

(...) as operações em discussão no processo (dez/2011) foram realizadas no exterior, quando o custodiante responsável pelos títulos negociados não mais era o Bradesco, e sim a *Tillerman Securities Ltd.* (fls. 316), de forma que o pedido probatório em análise é visivelmente impertinente, uma vez que se direciona à instituição que não era responsável pela custódia dos títulos no momento das negociações (...) ³³.

Por fim, saliente-se que o julgador deve analisar a necessidade de novas provas de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, de forma que, estando o processo suficientemente instruído, não se afigura necessária a produção de novas provas.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto pela inadmissão do extemporâneo pedido de produção de prova documental formulado pelo Acusado em petição datada de 10.08.2017.

No que se refere ao mérito da realização das provas, cuja produção sempre pode ser determinada pelo Relator do processo, entendo que, no caso, não existe necessidade, fundamento ou pertinência que justifique a sua realização, pelas razões já expostas nos itens 7 a 14 da presente decisão.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

¹ *Credit-linked notes*.

² "No caso da ocorrência de evento de crédito, e após confirmação da ISDA – International Swaps and Derivatives Association, o ativo é liquidado de acordo com percentual de valor pré-estabelecido em cada nota. Tal percentual é estabelecido em leilão realizado pelo ISDA, que leva em consideração o valor de mercado do ativo referência". Termo de Acusação, fl. 3.

³ Valor nominal.

⁴ Art. 96. Os fundos classificados como "Dívida Externa" deverão aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União, sendo permitida a aplicação de até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido em outros títulos de crédito transacionados no mercado internacional. [...]

⁵ Resposta da administradora ao OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/nº 2.282/2014, protocolada em 09.10.2014 (fls. 316).

⁶ "(a) Desde maio de 2011, todas as operações de crédito privado realizadas pela Atlântica para o Fundo deveriam ser submetidas à prévia aprovação do NY Mellon DTVM; e

(b) Desde junho de 2011, a Atlântica estava sujeita a um mecanismo de controle preventivo para todas as operações dos fundos sob sua gestão, antes da efetiva realização das mesmas, que deveriam ser submetidas previamente à análise e à aprovação da área de Enquadramento do BNY Mellon DTVM, para a verificação da adequação à metodologia contida no sistema de bandas de precificação, e posterior liquidação com as contrapartes, se aprovadas".

⁷ Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;

⁸ Os documentos apresentados pela Atlântica seriam somente "*indicative termsheet*", para fins de discussão (fls. 37 a 96) e uma minuta de versão final do *termsheet* (fls. 162/228), enquanto os documentos obtidos pela BNY Mellon junto ao emissor seriam a versão definitiva das notas por este emitidas (fls. 97 a 161 e 229 a 295).

⁹ Nos termos da NBC TA 560.

¹⁰ Art. 2º - São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...)

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes;

¹¹ §2º - Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos títulos e valores mobiliários dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para negociar, em nome do fundo de investimento, os referidos títulos e valores mobiliários. (Redação vigente até 08.05.2012).

¹² Parecer nº 00087/2015/GJU-4/PFE-CVM-PGF/AGU (fls. 463/464).

¹³ Parecer nº 00087/2015/GJU-4/PFE-CVM/PFG/AGU (fls. 463 a 464).

¹⁴ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado a prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹⁵ Despacho nº 00104/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 465).

¹⁶ Despacho nº 00454/2015/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 466).

¹⁷ Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: [...] 6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo, ou tribunal;

¹⁸ Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação, ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.

Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.

¹⁹ Fls. 1.249-1.268.

²⁰ Fls. 1.251; 1.258-1.259.

²¹ Fls. 413-414.

²² Fls. 413.

²³ A Defesa cita ainda Damásio de Jesus, Júlio F. Mirabete e Nelson Hungria e Fábio de Ulhoa Medina.

²⁴ REsp 1.251.697/ PR; REsp 962.265; AC 1997.34.00.025480-0/DF, TRF 1ª Região; AC 2004.34.00.003985-1, TRF 1ª Região.

²⁵ Recurso nº 12.454, Processo BCB 0701371310; e Recurso 4.447, Processo BCB 9900966674, ambos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

²⁶ I.A. CVM nº TA-RJ2002/2405: *"A doutrina que admite a condenação forte apenas em indícios baseia-se em alguns pontos que merecem destaque, notadamente a inexistência de hierarquia entre as provas; o princípio do livre convencimento fundamentado do Juiz e a própria referência do art. 239 do Código de Processo Penal à prova indiciária (...) As perplexidades e as dificuldades que envolvem a aceitação de indícios como elementos suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza que exige para condenar e no princípio in dubio pro reo"; e*

PAS 13/2009: *"Para a resolução de casos em que a prova direta torna-se impossível, a prova indiciária é fundamental, porquanto a solução somente seria viável na hipótese em que a intenção dos acusados pudesse ser pesquisada e afirmada, independentemente, é óbvio, de confissão. Entretanto, como qualquer meio de prova, um indício, ou mesmo um conjunto de indícios sem consistência, não é suficiente para a condenação (...)"* (fls. 1.240-1.243).

²⁷ No mesmo sentido, pode-se também citar, por analogia, o art. 336 do CPC: *"Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir"*. (g..n)

²⁸ Observe-se que, no processo administrativo sancionador, o acusado é intimado para apresentar defesa após a produção do conjunto probatório que a Área Técnica entendeu adequado e suficiente para fundamentar a acusação, de forma que, se tudo correr sem incidentes, o processo seguirá, após a defesa, para julgamento. A defesa é, portanto, o momento oportuno para o requerimento específico de produção de provas pelo acusado. Por sua vez, no processo judicial, com partes contrapostas, a situação é bem diferente, uma vez que, com a contestação do Réu, podem surgir novas questões em relação às quais o autor deve ter a oportunidade de manifestar-se e requerer novas provas, sendo comum, por conseguinte, a réplica e a possibilidade de nova instrução probatória.

²⁹ Tal entendimento encontra amparo, inclusive, na decisão proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN no âmbito do Recurso nº 13.440, julgado na 382ª sessão de julgamento realizada em 25.08.2015, bem como na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp: 1384971 SP2013/0149180-8, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, data de Julgamento: 02.10.2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 31.10.2014.

³⁰ Art. 22. Da decisão do Relator que negar pedido de diligências formulado pela defesa caberá recurso em separado ao Colegiado, mediante petição apresentada no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão do Relator.

³¹ Na realidade, as informações disponíveis no site da CVM são mais completas do que as de qualquer extrato, uma vez que é possível acessar não apenas a carteira de investimento, como também o balancete, os dados diários, os fatos relevantes, o Regulamento, a lâmina do fundo, as demonstrações contábeis com parecer do auditor e o perfil mensal (conforme documento anexo a este despacho).

³² Anote-se, ainda, sobre essa questão, que se encontram nos autos os demonstrativos da carteira de investimento do fundo desde nov/2011 até fev/2012 (fls. 329/360).

³³ Anote-se que o Acusado tinha plena ciência da transferência da custódia, tanto que afirma, no item 65 de sua defesa, que *"a transferência de Bradesco para o custodiante internacional não alterou em nada a posição da Atlântica frente ao tema custódia."*

Além disso, não há que se falar propriamente em contrato entre o Fundo e o Custodiante, uma vez que, nos termos do disposto no art. 56, § º, VI, da ICVM 409/04 (vigente à época), compete ao Administrador contratar o Custodiante.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/9909

Acusado: Fabrizio Dulcetti Neves

Assunto: Apurar a eventual ocorrência de infração ao disposto no inciso I da Instrução CVM nº 8/79 em razão da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

Relator: Diretor Gustavo Borba

Voto

SÍNTESE.

1. Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN", ou "Acusação") em face de Fabrizio Dulcetti Neves ("Fabrizio", ou "Acusado"), diretor responsável pela administração de carteiras de valores da Atlântica Administração de Recursos Ltda. ("Atlântica", ou "Gestora") durante o período em que esta esteve registrada na CVM¹, por supostamente ter causado prejuízo de mais de US\$ 79 milhões ao fundo *Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa* ("Fundo"), cujo cotista único era o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, em operações de investimento em títulos de dívida privados realizadas em dezembro de 2011 ("Operações").

2. Segundo o Termo de Acusação ("TA"), Fabrizio teria, como diretor responsável da Atlântica (fls. 23), realizado a compra, para o Fundo, de duas *Credit Linked-Notes*² ("Notas") com sobrepreço de aproximadamente US\$ 79 milhões, considerando as condições de mercado da época.

3. Essa suposta fraude teria sido descoberta pela *BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.* ("Administradora", ou "BNY"), que passou a exercer a gestão do *Brasil Sovereign II* em 01.03.2012, mas, apenas divulgou tal informação, por meio de fato relevante, em 04.08.2014.

4. As aquisições das *Credit Linked-Notes* do UBS ("UBS", ou "Emissor"), por meio de operação intermediada pelo Bank of Butterfield (subcustodiante), ocorreram em 20.12.2011 (fls. 324/325), tendo a Atlântica informado à BNY, em 18.01.2012, que estes títulos teriam custado US\$49.592.400,00 (82,654% do valor nominal) e US\$70.820.100,00 (90,795% do valor nominal) – ativos de ISIN XS0716257539 e XS0721046760, respectivamente – totalizando US\$120.412.500,00, o que estaria em sintonia com a avaliação supostamente realizada pela UBS nos *termsheets* de fls. 37 e 162, que teriam sido apresentados pela Atlântica para justificar as operações.

5. Ocorre que a BNY, por procedimentos internos, solicitou os *termsheets*³ das Notas à UBS (emitente), a qual apresentou documentos diversos daqueles enviados pela Atlântica, e que demonstravam que as *Credit Linked-Notes* estariam avaliadas, na realidade, por US\$17.340.000,00 (28,90% do valor nominal – ISIN XS0716257539) e US\$24.024.000,00 (30,80% do valor nominal – XS0721046760), o que totalizaria um montante quase US\$80 milhões inferior ao que foi efetivamente desembolsado pelo fundo na aquisição das notas.

6. Deste modo, pelo que foi apurado pela BNY Mellon, Fabrizio Dulcetti, na função de gestor do Fundo, teria pago US\$120.412.500,00 por títulos que valeriam US\$41.364.000,00, o que representa um sobrepreço de US\$79.048.500,00, apresentando posteriormente à Administradora, para justificar a operação, *termsheets*

adulterados que indicavam preços de emissão diversos dos que constavam dos *termsheets* finais originais, que foram fornecidos pela UBS, emissora das *Credit Linked-Notes*.

7. Segundo a documentação acostada aos autos, relacionada ao ativo XS0716257539, o *termsheet* que teria sido enviado, pela Atlântica à Administradora, para fins de justificação e contabilização da operação, seria um "*Indicative Termsheet – For Discussion Purposes Only*" (fls. 37 a 96). Apesar de esse documento indicar probabilidades implícitas de *default* no preço de 70%, 20% e 75% (relacionadas, respectivamente, às dívidas soberanas da Argentina, do Brasil e da Venezuela, que compunham a Nota) e que não haveria mercado secundário para a *Credit Linked-Note*, ainda assim o Fundo adquiriu essa nota por 82,654% do seu valor nominal.

8. O *termsheet* obtido junto ao Emissor UBS (fls. 97 a 161), no entanto, indica um preço de emissão de 28,9% do valor nominal dessa nota. Além disso, esse *termsheet* está devidamente assinado (fl. 110) e datado de 07.12.2011, constando ainda a indicação de "*Final Terms*".

9. Já em relação ao ativo ISIN XS0721046760, o *termsheet* apresentado à época pela Atlântica foi um "*Draft Final Terms*" (fls. 162 a 228). Apesar de os ativos subjacentes que compunham essa nota serem dívidas da Argentina, do Brasil e da PDVSA⁴, cujas probabilidades implícitas de *default* seriam de, respectivamente, 70%, 20% e 75%, e não existir mercado secundário para negociação, tal *Credit Linked-Note* foi avaliada a 90,795% do seu valor de face.

10. Também em relação a essa operação, os documentos fornecidos pela UBS possuem conteúdo diverso. O *termsheet* com a indicação "*Final Terms*" relativo a essa nota, obtido junto ao UBS e devidamente assinado (fls. 229 a 295), indica preço de emissão de 30,80% do seu valor de face, bastante inferior ao informado pela Gestora.

11. A tabela a seguir sumariza as divergências encontradas entre os documentos fornecidos pela Gestora Atlântica e pelo Emissor das Notas (UBS):

Ativo XS0716257539	Data Indicada no Termsheet	Valor Nominal	Preço de emissão	
			% do VN ⁵	US\$
Informações fornecidas pela Atlântica	15/12/2011	US\$ 60 milhões	82,654	49.592.400,00
Informações fornecidas pelo UBS AG	28/11/2011	US\$ 60 milhões	28,90	17.340.000,00
			Diferença	32.252.400

Ativo XS0721046760	Data Indicada no Termsheet	Valor Nominal	Preço de emissão	
			% do VN	US\$
Informações fornecidas pela Atlântica	19/12/2011	US\$ 78 milhões	90,795	70.820.100,00
Informações	14/12/2011	US\$ 78 milhões	30,80	24.024.000,00

fornecidas pelo <u>UBS AG</u>				
			Diferença	46.796.100

12. Afigura-se relevante, para a contextualização do caso, salientar que, em 29.12.2010, praticamente um ano antes das operações em tela, houve um pequeno desenquadramento passivo do fundo, que ocorreu devido à variação natural dos preços dos ativos da carteira. Como consequência, a percentagem em carteira de títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União Federal foi reduzida para o percentual de 79,87%, enquanto o art. 96 da ICVM 409/04 estabelecia que um fundo classificado como "Dívida Externa" deveria manter em carteira, no mínimo, 80% desse tipo de ativos⁶, regra esta que se encontra espelhada no regulamento do fundo (art. 8º, fls. 296/311).

13. Em função disso, e não tendo havido o reenquadramento da carteira sob a justificativa da Gestora de que este rebalanceamento traria prejuízos ao cotista⁷, a BNY expediu duas correspondências⁸ à Atlântica comunicando: i) que a partir de 16.05.2011 "todas as operações de crédito privado realizadas pela Atlântica para o Fundo deveriam ser submetidas à prévia aprovação do BNY Mellon DTVM" e, posteriormente, ii) que a partir de junho do mesmo ano (2011), todas as operações dos fundos sob gestão da Atlântica deveriam ser submetidas previamente à BNY (fls. 314 a 320).

14. Segundo a Administradora, como a Gestora era a responsável, conforme regulamento do fundo e regulação aplicável, pela efetiva compra e venda dos ativos do fundo, essa análise prévia só seria de fato realizada se a Atlântica tomasse a iniciativa de submeter antecipadamente tais operações à BNY, o que não teria ocorrido nas operações em questão, especialmente porque foram realizadas fora do Brasil, onde, conforme relatado pela Administradora, a liquidação das operações ocorre sem qualquer participação da administradora.

15. Em 24.01.2012, apenas seis dias após a Administradora ter sido informada da realização das Operações, a Atlântica solicitou a renúncia da administração do Fundo⁹.

16. É importante também destacar que a compra das Notas ocorreu após a venda da totalidade dos títulos de dívida externa brasileira que compunham a carteira do Fundo, provocando um desenquadramento agudo de sua carteira, tanto que o percentual de títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União ficou reduzido a 0% em 06.12.2011, o que violou flagrante e radicalmente o regulamento do Fundo e a regra da ICVM 409/04, conforme já exposto no item 12 supra. A administradora informou esse desenquadramento à POSTALIS em 20.01.12 (fls. 321).

17. Anote-se que os títulos de dívida externa brasileira do Fundo foram alienados por meio de duas transações realizadas em 06.12.2011, nos valores de US\$61.546.171,02 e de US\$58.866.843,53, totalizando US\$120.413.014,55, conforme boletas de venda constantes das folhas 416 e 417 dos autos¹⁰.

18. Assim, os recursos obtidos com a venda de títulos da dívida externa da União (US\$120.413.014,55) foram quase integralmente utilizados para a compra dos *Credit Linked-Notes* da UBS (US\$120.412.500,00), o que demonstra não apenas a sintonia entre a venda dos títulos de dívida externa brasileira para aquisição dos títulos da UBS, como também deliberada violação à composição de carteira previstas na ICVM 409/04 e no regulamento do Fundo.

19. Quanto a esse ponto, a SIN optou, em linha com a sugestão da PFE, por não acusar Fabrizio por infração ao art. 96 da ICVM 409/04, pois as vendas que geraram o desenquadramento do Fundo seriam “atos preparatórios e executórios da infração consumada (...) meios necessários e indissociáveis da conduta continente” (fl. 465).

20. Não se afigura pertinente avaliar a técnica acusatória neste momento processual, razão pela qual o voto tratará exclusivamente da acusação de infração ao inciso I, letra “c”, da Instrução CVM nº 08/79¹¹, nos seguintes termos:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;

21. Segundo a SIN, encontrar-se-iam presentes no caso os elementos necessários para tipificação de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, o que justificou a instauração do Processo Administrativo Sancionador.

22. Exposta a questão de forma panorâmica, passaremos à análise das preliminares e, após, ao mérito do caso.

PRELIMINARES.

23. A Defesa, como questão preliminar, sustenta que as provas colhidas pela Acusação não teriam validade jurídica por não terem sido encaminhadas pelo seu emissor (UBS), bem como porque o BNY teria “interesses conflitantes no processo”, por ser, inclusive, alvo de ação judicial movida pelo POSTALIS¹². Ademais, questiona a falta de tradução, registro em cartório de títulos e documentos e de consularização dos documentos anexados aos autos.

24. Cabe esclarecer, inicialmente, que os documentos relevantes ao caso foram traduzidos por tradutor juramentado, como se verifica às fls. 477 a 1156, o que torna evidente a inconsistência dessa preliminar.

25. No entanto, mesmo que não houvesse tradução juramentada, o que se admite para fins de argumentação, a circunstância de certos documentos estarem escritos em idioma inglês não acarretaria, no presente caso, qualquer nulidade, uma vez que se trata de idioma que o acusado inequivocamente domina, tanto que, além de residir nos EUA (conforme se extrai da procuração de fls. 1.190¹³), exerceu a gestão de um fundo de Dívida Externa com ativos custodiados em instituições estrangeiras, o que exige a perfeita compreensão da língua inglesa.

26. Assim, mesmo que os documentos pertinentes não estivessem traduzidos, o que se admite apenas para argumentar, não haveria qualquer prejuízo para a defesa do acusado, de modo que, segundo o princípio “*pas de nullité sans grief*”, e conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão¹⁴, não haveria como se cogitar nulidade da prova.

27. Quando à alegação de necessidade de registro dos documentos oriundos do exterior em Cartório de Títulos e Documentos, cumpre observar que essa medida, nos termos do disposto no art. 129, *caput*, da Lei 6.105/73, apenas é necessária para que o documento possa “*surtir efeitos em relação a terceiros*”, sendo certo que essa providência não é necessária para que o documento seja utilizado como prova em processo, conforme já definido pelo STJ, em acórdão da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi categórico ao afirmar que a “*exigência de registro de que trata os artigos 129, §6º, e 148 da Lei nº 6.015/73, constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova.*” (Recurso Especial STJ Nº 924.992 – PR; 2007/0027230-0).

28. No que se refere à inusitada alegação de necessidade de consularização dos *termsheets*, cabe esclarecer que o processo de consularização é cabível apenas para documentos oficiais de outro país ou para documentos particulares que contenham reconhecimento de firma de notário estrangeiro ou alguma outra chancela oficial, conforme decidido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão ao qual compete fiscalizar os Cartórios de Títulos e Documentos no referido Estado¹⁵. Assim, também rejeito essa preliminar.

29. Quanto às alegações de que os documentos não foram fornecidos diretamente pela UBS, emissora dos títulos, mas, sim pelo BNY Mellon, cumpre observar que essa situação está em total sintonia com a regulação aplicável, uma vez que cabe à Administradora obter os documentos e informações relacionados ao fundo, de forma que disso não se poderia extrair qualquer espécie de nulidade. De qualquer forma, considerando as alegações do Acusado de que a *BNY Mellon* seria interessada no caso, cumpre observar que essa alegação será levada em consideração durante a análise do mérito, de modo a ponderar as provas fornecidas pela Administradora com as demais circunstâncias e provas relacionadas ao caso.

30. Por fim, quanto aos pedidos de provas apresentados, cumpre reiterar a decisão proferida em 14.08.2017 e reproduzida no item 71 do relatório, que os rejeitou.

31. Superadas as questões preliminares, passemos à análise dos argumentos de mérito do defendente.

MÉRITO.

I - DA RESPONSABILIDADE DO GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.

32. Fabrizio dedica boa parte de sua defesa, transferindo a responsabilidade pelas irregularidades ocorridas exclusivamente para a Administradora, pois, segundo alega, de acordo com a ICVM 409/04 e o contrato firmado com a POSTALIS, caberia à Administradora a escolha da corretora e do custodiante, bem como a precificação e o registro dos ativos e de conciliação das operações.

33. Conforme precedentes do Colegiado¹⁶, a ICVM 306/99 já atribuía responsabilidade aos gestores de carteiras de investimento sempre que o administrador não cumlasse essa função.

34. Sobre a abrangência do disposto no art. 65, inciso XIII¹⁷, da ICVM 409/04, cumpre observar que essa questão também se encontra superada pelos precedentes do Colegiado¹⁸, posto que, mesmo antes da edição da ICVM 558/15 (que definiu mais claramente as responsabilidades do gestor de fundos de investimento), a interpretação

sistemática da ICVM 306/99 e da ICVM 409/04 já era no sentido de que o gestor de fundos de investimento seria responsável pelos atos realizados dentro de suas atribuições, independentemente das demais obrigações e responsabilidades que permaneceriam com o administrador.

35. Não há dúvida, portanto, que, quando dos fatos ora em análise (dez/2011 e janeiro/2012), as regras das ICVMs 409/04¹⁹ e 306/99²⁰ tratavam dessa responsabilidade de forma muito clara, como, por exemplo, no art. 65-A, da ICVM 409, vigente desde 2007, que prevê que o Gestor deve responder “*por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua (...) gestão*” (inciso I) em virtude da violação aos deveres de “*cuidado*”, “*diligência*” e “*lealdade*” ou quando “*ferir a relação fiduciária*” com os cotistas.

36. No mesmo sentido, podemos ainda citar o art. 13 e o §2º do art. 63, da ICVM 409/04, que preveem, respectivamente, a responsabilidade do gestor por violação das regras de investimento²¹ e que a existência de comitês não exime de responsabilidade o gestor quanto às operações da carteira do fundo²².

37. Anote-se, por fim, que o próprio regulamento do Fundo previa poderes para a Gestora “*negociar, em nome do FUNDO, os referidos títulos e valores mobiliários*” (art. 3º, parágrafo único – fls. 296), bem como que os prestadores de serviço ao Fundo “*respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do FUNDO e às disposições regulamentares aplicáveis*” [art. 10, §3º (fls. 299)].

38. Diante dos termos da regulação da CVM vigente à época e do próprio regulamento do fundo, constata-se a total inconsistência dos argumentos apresentados pela defesa para sustentar a ausência de responsabilidade da Gestora em virtude de eventuais malfeitos realizados no exercício de suas funções.

39. Além disso, a circunstância de a SIN ter deixado de formular acusação contra o BNY²³ não exime a Gestora de suas responsabilidades, uma vez que a responsabilidade de uma não depende da do outro, de modo que cada um deve ser responsabilizado por seus atos e omissões dentro de suas atribuições, independentemente de eventual corresponsabilidade de outro regulado, questão que será melhor analisada no capítulo seguinte.

40. Acrescente-se ainda que a responsabilidade administrativa, ora em análise, não se confunde com a responsabilidade civil, de modo que nada impede que a administradora responda civilmente por atos culposos, ou dolosos, sem que isso exima a gestora de sua responsabilidade administrativa, que, como já afirmado, é autônoma e depende exclusivamente da conduta de cada um²⁴.

41. Não procede, destarte, a alegação do acusado de que a Gestora não deve responder pelos seus atos irregulares relacionados à gestão do Fundo.

II - DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR E CONTROLADOR TOTALITÁRIO DA GESTORA.

42. Cumpre destacar que Fabrizio era o **diretor responsável** da Atlântica, conforme se verifica no documento de **fls. 23**, bem como seu sócio totalitário, tanto que possuía, direta, ou indiretamente, 100% do capital social²⁵, o que lhe garantia controle total sobre as operações da Gestora, com as consequentes responsabilidades administrativas, conforme regulação aplicável da CVM.

43. Assim, como **diretor responsável** e controlador, não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade do Acusado pela gestão das operações em discussão, nos termos do disposto no art. 7º, II, da ICVM 306/99.

44. No caso, ficou muito claro, pelas provas e demais evidências obtidas, que o Acusado, como diretor responsável e sócio totalitário da Atlântica, foi o autor material dos atos em análise, razão pela qual não há qualquer pertinência nas alegações da defesa sobre responsabilidade objetiva.

45. Além disso, a circunstância de o Acusado ser o Diretor Responsável da Atlântica, devidamente indicado à CVM (fl. 23), já atrai para si uma série de obrigações de controle e fiscalização que também não se confundem com responsabilidade objetiva, tanto que, conforme precedentes da CVM, está pacificado que a criação pela regulação de centros de imputação não afetam o caráter subjetivo da responsabilidade do regulado, posto que a falha na implantação de controles apropriados pelo responsável pela área evidenciaria o aspecto subjetivo, conforme já decidido pelo Colegiado da CVM em precedente relatado pela Diretora Luciana Dias em 06.12.2012 (PAS nº 08/2004):

"12. A nomeação de um diretor responsável perante a CVM é um mecanismo cuja finalidade é a criação de um núcleo de imputabilidade nos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários. Aos diretores é atribuída a qualidade de centros de imputação de responsabilidade. Esses diretores têm plena ciência desta qualidade quando assumem os respectivos cargos. Trata-se de uma estratégia regulatória legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas internas desses prestadores de serviços, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais regulamentares, provenientes da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

13. A responsabilização dos centros de imputação muitas vezes prescinde da individualização específica da conduta. Essa estratégia, porém, está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O diretor responsável sempre pode comprovar que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos foram satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade do diretor."

46. No caso, contudo, não há sequer a alegação da defesa quanto à existência de sistemas de controle ou mesmo que a responsabilidade pelos atos seria de outro diretor, o que evidencia de forma indelével a responsabilidade do Acusado pelos atos em tela, seja pela omissão na criação de controles, seja porque as provas e evidências constantes dos autos demonstram que o Acusado foi, na realidade, o responsável pela realização das operações em tela²⁶.

III - DA CONDUTA DO ACUSADO NO CASO CONCRETO.

47. Em sua defesa, o acusado utilizou a estratégia de negar quase tudo que lhe foi imputado, ao ponto de afirmar que não mais possuía poderes de gestão desde maio de 2011²⁷ e que, portanto, não teria participado das operações em questão.

48. Diante dessas circunstâncias, e para que possamos prosseguir em bases sólidas, cumpre inicialmente registrar que, apesar dessa estratégia da defesa, ainda assim existem alguns atos incontestados no presente processo, posto que envolvem situações afirmadas pela acusação ou demonstradas em documentos que instruíram o processo e que não foram negadas pelo Acusado, de forma que a veracidade dessas circunstâncias é inquestionável, conforme regra básica de hermenêutica processual.

49. No caso, existem os seguintes fatos incontestados que são relevantes: i) Priscilla Lima era funcionária do *back-office* da Atlântica; ii) Priscilla Lima realmente enviou email para a Administradora no dia 18.01.2012 fazendo referência a "*boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*"; iii) a Atlântica requereu renúncia à função de gestora do Fundo apenas em 24.01.2012 (fls. 368 a 370); e iv) o preço de aquisição das *Credit Linked-Notes* da UBS por US\$120.412.500,00 estava superavaliado, considerando as características dos títulos e os ativos subjacentes²⁸.

50. Esses pontos incontestados são essenciais à correta compreensão da situação, com o que se pode verificar diversas inconsistências na defesa do acusado.

51. A principal tese de defesa consiste na alegação de que a Atlântica já não exercia a função de gestora do Fundo em dezembro de 2011, sob o argumento de que cartas enviadas pela Administradora durante o ano de 2011 teriam retirado os poderes da Gestora.

52. As cartas, a que faz referência a defesa, foram enviadas pela Administradora nos dias 13.05.2011 e 01.06.2011, e, em síntese, "rogavam" à Gestora que as operações de compra e venda de ativos do Fundo fossem submetidas à prévia aprovação da Administradora.

53. Essas cartas, como se afigura evidente, não possuíam força jurídica para retirar o poder de gestão da Atlântica, que já estava, há muito tempo, formalmente investida nesses poderes, como inclusive indicava o próprio Regulamento do Fundo. Não há dúvida de que, nessas circunstâncias, a destituição da função demandaria deliberação em assembleia dos cotistas, conforme se encontra claríssimo no art. 18 do Regulamento do Fundo, que assim dispõe:

Art. 18 – É de competência privativa da assembleia geral de cotistas do FUNDO deliberar sobre:

(...)

II a substituição da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou da CUSTODIANTE do fundo;

54. Mais do que isso, a própria regra geral da ICVM 409/04 já determinava que a destituição do Gestor seria por deliberação da assembleia:

Art. 66. O administrador e o gestor da carteira do fundo devem ser substituídos nas hipóteses de:

(...)

III – destituição, por deliberação da assembleia geral.

55. Afigura-se, portanto, evidente que a mera solicitação de prévia aprovação pela Administradora não alterava, em hipótese alguma, os poderes de gestão da Atlântica, que assim continuava com plenos poderes para realizar as aquisições e vendas de ativos do fundo, conforme regras que constavam explicitamente tanto do Regulamento do Fundo, que previa os **poderes para a Gestora "negociar, em nome do FUNDO, os referidos títulos e valores mobiliários"** (art. 3º, parágrafo único – fls. 296), como do

inciso I do §2º do art. 56 da ICVM 409/04, que é expressa quanto aos poderes do gestor para "**negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo**"²⁹."

56. Assim, a não submissão da operação previamente à Administradora seria apenas o descumprimento de um suposto compromisso entre as duas entidades (talvez nem mesmo compromisso, mas a mera solicitação da Administradora), o que não impediria, de forma alguma, a realização das operações pela Gestora.

57. Assim, considerando que a Atlântica requereu a renúncia da gestão em 24.01.2012 (fato incontroverso e comprovado pelo documento de fls. 368 a 370), afigura-se inequívoco que ela permanecia como gestora do fundo em dezembro de 2011, quando das operações de alienação dos títulos de dívida externa brasileira e da subsequente aquisição superfaturada pelo Fundo das *Credit Linked-Notes* da UBS no mesmo mês (dez/11), por meio de operação intermediada pelo Bank of Butterfield (subcustodiante)³⁰.

58. Destarte, as alegações da defesa de que a Atlântica não deteria poderes de gestão em virtude das referidas cartas são totalmente desconectadas do sistema de funcionamento dos fundos de investimento e da regulação aplicável, razão pela qual rejeito esse argumento, uma vez que as provas dos autos demonstram exatamente o oposto, ou seja, que a Atlântica estava no pleno exercício da gestão no mês de dezembro de 2011.

59. Para ser mais preciso, em dezembro de 2011, quando foram realizadas as operações em discussão, a **Atlântica seria a única habilitada a fazer essa operação**, uma vez que ela permaneceria sendo a exclusiva pessoa formalmente investida do poder de gestão do Fundo, do qual apenas foi destituída no final de fevereiro de 2012, após as fatídicas operações ora em análise.

60. Nesse contexto, como a custodiante estrangeira *Tillerman Securities Ltd.* teria que verificar, para realizar as operações, quem detinha os poderes de gestão, e como a Atlântica estava efetiva e formalmente investida desses poderes, não há como acolher a alegação do Acusado de que ele não realizou essa operações³¹.

61. Mesmo se admitindo, para fins de argumentação, e contra toda a lógica de confiança que fundamenta o sistema internacional regulado de negociação de valores mobiliários, que teria havido um grande conluio entre a Administradora *BNY Mellon do Brasil* com a custodiante estrangeira *Tillerman Securities Ltd.* e a central depositária internacional Euroclear para permitir que outra pessoa, não regularmente autorizada, tenha realizado as operações, ainda assim melhor sorte não acudiria ao acusado, pois as demais circunstâncias e fatos deixam clara a inconsistência da tese defensiva, como se passa a demonstrar.

62. A argumentação da defesa de que o Acusado não participou das Operações apresenta-se inconsistente pelas seguintes razões: i) o Acusado requereu a renúncia da função de gestão do Fundo em 24.01.12, de forma que não poderia alegar que em dezembro de 2011 estaria desprovido dos poderes de gestão; ii) se não exercia mais essas funções, porque a secretaria executiva da Gestora teria enviado email em 18.01.2012 (fato incontroverso), para a Administradora, fazendo referência a "*boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*"?; iii) se esse email de 18.01.2012 fosse sobre outro "negócio", porque o acusado não indicaria qual seria esse outro negócio?; iv) a qual outro negócio poderia esse email se referir, se a totalidade dos títulos de dívida externa brasileira haviam sido vendidos em dez/11 para a aquisição dos *Credit Linked-*

Notes no mesmo mês; e v) se o anexo do email fosse diverso do *termsheet* apresentado pelo Administrador, porque o Acusado não apresentou o suposto anexo “verdadeiro”?

63. Essas perguntas, desprovidas de resposta que possam sustentar a tese de defesa, bem como os demais elementos constantes do processo, demonstram a preponderância de evidências que são suficientes para fundamentar a conclusão de que o Acusado foi quem efetivamente realizou, como responsável pela gestão do fundo, a desastrosa e maliciosa operação que promoveu um desfalque de mais de U\$ 79 milhões no fundo de pensão POSTALIS, prejudicando, em consequência, milhares de aposentados, pensionistas e participantes em atividade do fundo.

64. Os emails enviados pela funcionária da Atlântica de nome Priscilla³² para a Administradora (fls. 413 a 415), em 18.01.2012, a partir de uma conta do domínio @atlanticaasset.com.br³³, tornam essa questão superada, pois, se a gestora tivesse tido seus poderes de gestão subtraídos, não haveria porque existir essa troca de mensagens eletrônicas, nas quais são discutidos detalhes dos comprovantes necessários para o processamento de operações:

11h01: Email de S.B., funcionário do BNY, a Priscilla, funcionária da Atlântica:

"Priscila, Precisamos receber as boletas dos trades para reprocessarmos as carteiras.

Vc pode me enviar? Obrigado" (sic);

14h10: Email de Priscilla para S.B.:

"[S.], Conforme contato, segue o extrato com as movimentações, Atenciosamente, Priscilla [L.]";

15h51: Email de S.B. para Priscilla:

"Preciso falar com urgência com vc. Pode me ligar no celular. [S.B.]";

16h33: Email de Priscilla para S.B.:

"[S.], Conforme nos falamos, segue as boletas com o accrued e as Term Sheet das NP. Atenciosamente, Priscilla"; (g.n.)

16h42: Email de S.B. para vários recipientes:

"[F/T] Por favor, cadastrem o ativo. [D/R], Seguem as boletas corretas de venda. Abs".

65. Conforme informado pela Administradora, nos anexos de tais e-mails estariam as cópias dos *termsheets* com os valores superfaturados ("*Indicative Termsheet*" e "*Draft Final Terms*", descritos nos parágrafos 0 e 0) e as boletas confirmando a venda dos títulos de dívida externa brasileira.

66. O Acusado, diante dessas evidências, limita-se a desqualificar a possibilidade do email como prova, mas não nega que tenha havido efetivamente essa troca de mensagens eletrônicas, nem que Priscilla fosse sua funcionária e que ela estivesse agindo em nome da Gestora. Essas circunstâncias são incontroversas, de forma que não há dúvida de que a Gestora trocou mensagens eletrônicas com a administradora sobre "*boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*", o que faz cair por terra toda a argumentação do Acusado de que não estaria mais exercendo a gestão do Fundo e que não teve nenhuma participação operações discutidas no presente processo.

67. Se não exercia mais nenhuma atividade para o Fundo, por qual razão iria a Gestora trocar uma série de mensagens eletrônicas sobre "*boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*" justamente no dia 18.01.2012, mês seguinte ao da realização das operações fraudulentas?

68. Ademais, se os anexos dos e-mails fossem sobre assunto diverso, porque fariam referência a "*boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*"? Mais do que isso, como o

Fundo teria zerado seus títulos em dívida brasileira para adquirir as notas emitidas pelo UBS, a qual outra operação do fundo poderia fazer referência o referido e-mail?

69. Além disso, só haveria lógica em mandar essas *termsheets* para a Administradora se as avaliações nelas indicadas estivessem em sintonia com as operações realizadas, razão pela qual tudo demonstra que as *termsheets* anexas ao email da Atlântica realmente eram aquelas versões adulteradas de fls. 37 e 162.

70. Anote-se, por relevante, que esses *termsheets* de fls. 37 a 96 e 162 a 228, enviados pela Gestora à Administradora, não eram, na verdade, "minutas" (*drafts*), mas sim documentos efetivamente adulterados, o que fica claro quando se verifica que foram elaborados em 15.12.2011 e 19.12.2011, ou seja, em datas posteriores às dos *termsheets* verdadeiros e finais enviados pela UBS (emitente), que datam de 28.11.2011 e 14.12.2011. Em outras palavras: se fossem realmente minutas jamais poderiam ser posteriores aos documentos finais!

71. Diante de todos os indícios fortes e convergentes que existem contra o Acusado, seria mais do que natural que ele apresentasse, em sua defesa, o suposto documento diverso que estava anexado ao email do dia 18.01.12, isto, é as *boletas com o accrued e as Term Sheet das NP* relacionadas a supostas outras operações diversas da aquisição das duas *Credit Linked-Notes* emitidas pela UBS.

72. A defesa, no entanto, não apresentou qualquer documentação ou argumento hábil que pudesse enfraquecer todo o conjunto probatório robusto que demonstra ter sido a Atlântica, durante o período que exercia inequivocamente a função de gestora do Fundo, que realizou as operações fraudulentas em tela, inclusive enviando à Administradora, após realização dos negócios, as *boletas com o accrued e as Term Sheet das NP*.

73. Por fim, cumpre observar que a defesa, em sua maior parte, limita-se a levantar uma série de supostas irregularidades cometidas pela Administradora, afirmando, por exemplo, que a *BNY Mellon* não deveria contabilizar o operação apenas com um e-mail, ou transferir a custódia para o exterior, ou ainda que ela deveria tomar medidas após a realização das operações³⁴.

74. Como se afigura evidente, eventuais irregularidades cometidas pela Administradora não eximem de responsabilidade a Gestora pelos atos que esta efetivamente realizou, como foi, no caso, a venda dos ativos do fundo para adquirir, imediatamente após, duas *Credit Linked-Notes* superfaturadas, obstando a percepção do golpe por meio de envio de documentação adulterada.

75. Desta forma, essas alegações relacionadas à conduta da *BNY Mellon* são ineptas para sustentar a defesa do acusado, tanto que, mesmo se fossem procedentes, ou seja, mesmo se viesse a ser concluído que a *BNY Mellon* agiu equivocadamente quando permitiu a transferência da custódia para o exterior, ou quando considerou o valor da operação adequada com base em avaliação constante de minuta de *termsheets*, ainda assim essas circunstâncias não eximiriam de culpa o Acusado, em virtude das operações fraudulentas realizadas durante a sua gestão, mas, apenas agregaria a corresponsabilidade da administradora, questão esta que, no entanto, apenas pode ser analisada em outro procedimento, considerando os limites subjetivos deste PAS (a *BNY Mellon* não está sob julgamento no presente caso).

IV - CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA (INCISO I, LETRA “C” , DA INSTRUÇÃO CVM Nº 08/79).

76. Quanto aos requisitos para a configuração de operação fraudulenta (ICVM 08/79, I, “c”), afigura-se necessário que o acusado tenha atuado com a finalidade “*de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros*” e utilizado “*ardil ou artifício*” que “*induza ou mantenha um terceiro em erro*”.

77. Parece-me claro, diante das provas trazidas aos autos, que o ardil utilizado por Fabrizio foi adquirir as *Credit Linked-Notes* superfaturadas e apresentar *termsheets* adulterados à Administradora, com o que dificultou a detecção da fraude realizada (sobrepço) por parte da Administradora, do Postalís e de todos os seus participantes (ativos, aposentados e pensionistas), o que demonstra a indução e manutenção de terceiros em erro.

78. Anote-se que, em casos como o presente, os terceiros induzidos ou mantidos em erro são também, conforme precedentes da CVM³⁵, os participantes do fundo de previdência, que é cotista do fundo de investimento no qual foi realizada a operação fraudulenta.

79. Desta forma, as Notas foram adquiridas por valor incompatível com as condições de mercado, mas, os prejudicados não puderam perceber a fraude em virtude dos documentos adulterados que o Acusado ardilosamente utilizou para instruir a operação. Por outras palavras, pode-se dizer que, caso fossem apresentadas as *termsheets* verdadeiras, que demonstravam que as *Credit Linked-Notes* da UBS indicavam um deságio de 28,90% e 30,80% sobre os valores de face, as operações irregulares seriam fácil e rapidamente descobertas, pois ficaria escancarado que os percentuais aplicados de 82,654% e 90,795% sobre o valor de face seriam incompatíveis com as operações.

80. Outra circunstância que demonstra a premeditação do golpe decorre do fato de os títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União Federal terem sido vendidos, em 06.12.2011 (trade date)³⁶, por US\$120.413.014,55³⁷, e, logo após o efetivo recebimento (extrato às fls. 328), os recursos obtidos foram utilizados para a aquisição das *Credit Linked-Notes* em 20.12.11 (fls. 324/325), por US\$120.412.500,00, valor praticamente idêntico ao da referida venda pretérita.

81. Considerando os valores de mercado dos *Credit Linked-Notes* (conforme avaliação do emitente UBS indicado nos *termsheets* de fls. 97 e 229), que eram de US\$17.340.000,00 e US\$24.024.000,00, e os valores que foram pagos pelo gestor do fundo para a realização da operação (US\$49.592.400,00 e US\$70.820.100,00), verifica-se uma diferença entre ambos no montante de US\$79.048.500,00, que representa o benefício auferido pelo acusado ou por terceiros em conluio com ele.

82. É importante, neste ponto, destacar a irrelevância de se comprovar a destinação dos recursos – o que só seria possível fazer lançando-se mão da quebra de sigilo bancário de Fabrizio, da Atlântica e do *Bank of Butterfield* (que intermediou a operação como subcustodiante), uma vez que o dispositivo regulamentar da ICVM 08/79 determina que a mera finalidade, ou seja, a intenção de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes já é suficiente para caracterizar a ocorrência de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários³⁸.

83. Acrescente-se, por fim, que a finalidade de obtenção de vantagem ilícita para terceiros fica clara quando a Gestora faz o Fundo pagar U\$120.412.500,00 por títulos que estavam avaliados, pelo próprio Emitente (UBS), por U\$41.364.000,00, e ainda encaminha documentos adulterados (*termsheets*) para ocultar a fraude, tudo em benefício da contraparte da operação intermediada pelo *Bank of Butterfield*, e, naturalmente, à custa do patrimônio do Fundo³⁹.

84. Por todo o exposto, entendo que Fabrizio Dulcetti Neves deve ser condenado por infração ao disposto nos incisos I e II, "c", da Instrução CVM nº 08/79, por prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

DOSIMETRIA DA PENA.

85. Quanto à dosimetria da pena, entendo que, em casos como o presente, em que o acusado realiza operação fraudulenta para obter benefício financeiro para si ou para outrem em conluio, o critério mais adequado para aplicação da multa é o do art. 11, §1º, III, da Lei 6.385/76, pois a vinculação da pena ao benefício auferido ou prejuízo evitado é mais proporcional e ajustada à finalidade dissuasória da penalidade, uma vez que o risco de o infrator ter que devolver até três vezes o benefício irregular configura um efetivo desestímulo econômico à realização da irregularidade.

86. Nessa linha de raciocínio, apenas quando a multa é superior ao benefício auferido o efeito dissuasório da pena torna-se efetivo, tanto para o punido como para os demais agentes que eventualmente estejam inclinados à realização de irregularidades, uma vez que, também pela perspectiva econômica, passa a ser desvantajosa a atuação irregular⁴⁰.

87. É importante ressaltar que, como já exposto nos itens 81/83, em menos de um mês as Notas em questão foram criadas e avaliadas pela UBS, negociadas no mercado e revendidas ao Fundo⁴¹, de forma que a diferença entre a avaliação do emissor (UBS) e o valor pago pelo Fundo para adquirir as Notas representa, com suficiente precisão, o montante do benefício auferido pelo Acusado e/ou terceiros que estavam em conluio com ele.

88. Quando à extensão do conceito de benefício auferido, reitero a posição por mim adotada no PAS CVM nº 03/2012, quando afirmei que, para sua apuração, deve ser considerado tanto o benefício recebido diretamente pelo acusado como por terceiros que estejam em conluio com ele:

"Desta forma, adoto o critério previsto no art. 11, § 1º, III, da Lei 6.385/76, para aplicar ao acusado multa no valor correspondente a '3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida (...) em decorrência do ilícito', o que considero, no caso, permitir uma dosimetria mais adequada e ajustada ao grau de dolo e gravidade da conduta em questão, bem como ao vulto do prejuízo imputado à companhia. Para tanto, interpreto o conceito de 'vantagem econômica obtida', previsto no inciso III do § 1º do art. 11 da Lei 6.385/76, como incluindo tanto o benefício obtido pelo próprio acusado, como o que for obtido por terceiros, em conluio, em virtude da conduta irregular do acusado, uma vez que essas situações estão visivelmente incluídas na margem interpretativa do referido dispositivo legal."

89. De fato, caso a regra fosse interpretada apenas como o benefício auferido pelo próprio acusado, estar-se-ia adotando exegese que seria incompatível com o objetivo da

norma e que estimularia a realização de operações irregulares que beneficiassem terceiros relacionados ou em conluio, o que não entendo ser o posicionamento mais adequado.

90. No caso, como já demonstrado nos itens 79/81, o benefício auferido pelo acusado, pelo terceiro em conluio⁴² que operou por intermédio do subcustodiante *Bank of Butterfield* e por outras pessoas que eventualmente façam parte do esquema fraudulento totalizou o montante de US\$ 79.048.500,00, que deve ser o parâmetro utilizado para aplicação da pena com fulcro no art. 11, §1º, III, da Lei 6.385/76, não importando quanto do total ficou com cada um, como já exposto no item 82.

91. Em relação ao número de vezes que o benefício indevido será utilizado para fixação da pena, entendo que o caso em questão é de gravidade máxima, uma vez que o gestor, que deveria atuar no interesse do fundo (*Gatekeeper*), promoveu atos dolosos e premeditados para expropriar do fundo de investimento a colossal quantia de US\$ 79.048.500,00. Agrava a situação o fato de o "cotista único" ser o POSTALIS, do que decorre que a fraude foi realizada em prejuízo do patrimônio comum de milhares de aposentados, pensionistas e participantes ativos.

92. Nesse contexto, apesar de a aplicação da pena no patamar máximo, de três vezes o benefício auferido, conduzir a uma multa bastante elevada, entendo que, diante da extrema gravidade dos fatos, não haveria como se adotar outro patamar. Ademais, a multa apenas será tão elevada em decorrência de o benefício auferido em virtude da fraude ter sido de grande magnitude, o que evidencia a razoabilidade proporcional da pena.

93. Quanto ao momento de conversão do câmbio, entendo que deve ser adotado, para tanto, a data em que as operações efetivamente ocorreram, que foi o dia 20.12.2011 (fls. 324/325). A diferença entre os valores que foram pagos e os que deveriam ter sido pagos será convertida pela média dos valores de compra e venda do dólar PTAX⁴³ informado pelo Banco Central do Brasil.

94. Os valores de dólar informados pelo Banco Central do Brasil foram, para a data de 20.12.2011, R\$1,8501 para compra e R\$1,8508 para venda, resultando em um valor médio de R\$1,8505.

95. Assim, considerando o sobrepreço apurado de US\$79.048.500,00 (item 0) e adotando a metodologia acima indicada, chega-se ao montante de R\$146.279.249,25 (cento e quarenta e seis milhões duzentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) como sendo o total de benefício auferido, em virtude da operação fraudulenta, pelo Acusado e terceiros em conluio.

96. Por fim, para evitar qualquer interpretação equivocada, esclareço que foi aplicado, na fixação da pena, o critério legal vigente no momento da realização dos atos em discussão (dez/2011 e jan/2012), sem qualquer influência das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 784, que, naturalmente, em relação às penas, apenas pode ser aplicada de forma prospectiva.

CONCLUSÃO.

97. Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, c/c os incisos I e II, "c", da Instrução CVM nº 08/79, **voto:**

a) pela **rejeição** das preliminares de invalidade jurídica das provas;

- b) pelo **indeferimento** do pedido de abertura de novo prazo para produção de provas; e
- c) pela **condenação** de **Fabrizio Dulcetti Neves**, na condição de diretor responsável pela Atlântica Administração de Recursos Ltda., gestora do *Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa*, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$438.837.747,75 (quatrocentos e trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)**, equivalente a três vezes⁴⁴ o ganho econômico obtido com a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

98. Por fim, determino que o Ministério Público Federal seja comunicado do resultado deste julgamento, bem como que seja remetida cópia do presente voto à SIN, para que aquela Superintendência avalie, diante do contexto geral analisado na presente decisão, a eventual conveniência de um estudo mais aprofundado quanto à eventual propositura de PAS contra a Administradora.

É o voto.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

¹ De 26.07.2006 a 08.07.2013 (fl. 27).

² "Termo em inglês para definir um título mobiliário que permite ao emissor transferir para os investidores um risco de crédito específico. O pagamento do principal e dos juros desses títulos está vinculado à ocorrência de um determinado evento de crédito. CLN podem ser emitidos por instituições financeiras, empresas ou SPE. No caso de CLN emitidos por instituições financeiras, ou empresas (compradores de proteção), os investidores (vendedores de proteção) correm o risco de crédito destas e do crédito específico que se busca transferir" (http://manual.uqbar.com.br/porta/Manual/default/Content?action=2&uri=/Manual/C/credit_linked_note_cln.html).

³ Documento detalhado contendo o preço, as características e demais informações dos títulos emitidos pela UBS.

⁴ Petróleos de Venezuela S.A.

⁵ Valor nominal.

⁶ Da ICVM 409/2004, vigente à época: "Art. 96. Os fundos classificados como "Dívida Externa" deverão aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União, sendo permitida a aplicação de até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido em outros títulos de crédito transacionados no mercado internacional".

⁷ A CVM foi comunicada pela Administradora por meio de "Comunicação de Desenquadramento de Carteira" às folhas 361.

⁸ Datadas de 13.05.2011 e 01.06.2011 (fls. 319 e 320, respectivamente).

⁹ Ao contrário do que afirma o Acusado, em e-mail de 15.06.2015, de que tal rescisão teria ocorrido em 15.06.2009. Esta, segundo o contrato anexado aos autos (fls. 368 a 370), foi a data de assinatura do contrato de gestão entre a Atlântica e a BNY. O mesmo documento informa, em seu item III, que **a Gestora renunciou ao seu cargo em 24.01.2012**, e que, a partir de 01.03.2012, esta seria substituída por outra empresa de gestão. (g.n.)

¹⁰ De acordo com o Relatório de Carteira Diária – Fechamento da posição em 31.01.2012, as *Credit Linked-Notes* totalizavam aproximadamente 71% da carteira do Fundo. Os demais ativos já eram títulos privados adquiridos em 2009 (fl. 322).

¹¹ A ICVM nº 08/79 foi editada com fulcro no art. 18, II, "b", da Lei 6.385/76:

Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...)

II - definir: (...)

b) a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não equitativas na distribuição ou intermediação de valores; (...)

¹² Observe-se, contudo, que a responsabilidade civil de natureza contratual da Administradora em nada influi na questão da responsabilidade administrativa da Gestora.

¹³ A procuração de fls. 1.190 informa que o acusado Fabrizio possui domicílio na 1710 South Miami Ave., Miami, Florida, Estados Unidos da América.

¹⁴ A título de exemplo, podemos citar o REsp 616.103/SC, 1ª Turma, Ministro-Relator Teori Zavascki, DJ de 27.09.2004, e o REsp 1.231.152/ PR, 3ª Turma, Min. Rel Nancy Andrighi, DJ de 18.10.2013.

¹⁵ "Registro de Títulos e Documentos - Consulta a respeito da necessidade de "notarização" e "consularização" de documentos oriundos do exterior - Exigência afeta apenas aos documentos provenientes de autoridade

estrangeira, ou nos quais tenha havido intervenção de notário ou registrador - Desnecessidade quando se tratar de documento particular que não esteja em uma dessas situações - Inteligência do art. 129, 6º, da Lei dos Registros Públicos e do art. 3º do Decreto 84.451/84". CGJSP - PROCESSO: 118647/2010 CGJSP – Processo, localidade: São Paulo; data de julgamento: 05.07.2011; Relator: Maurício Vidigal.

¹⁶ Nesse sentido, o voto proferido pelo Diretor-Relator Marcos Pinto no PAS CVM nº RJ2006/4663, julgado em 04.09.2007, conclui que: “1.9 - *Em resumo: tanto a Circular BACEN nº 2.616/95 quanto a Instrução CVM nº 306/99 são aplicáveis ao caso em exame. Nesse aspecto, as alegações da defesa são equivocadas e o termo de acusação não merece qualquer reparo*”. No mesmo sentido, pode-se citar os Processos Administrativos Sancionadores CVM números 01/2005, julgado em 26.11.2008, o RJ2005/8542, julgado em 23.05.2007, e o 07/2012, julgado em 07.03.2017.

¹⁷ Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...)

XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;

¹⁸ Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes, no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/6987, julgado em 08.11.2014, acompanhado por unanimidade pelo Colegiado: “10. *Com relação à alegação da Defesa de que o art. 65, XIII, não seria aplicável ao gestor de fundo de investimento, é importante deixar claro que apesar do caput do referido artigo fazer referência apenas ao termo 'administrador', ele deve ser interpretado de forma sistemática. No caso concreto, não seria lógico exigir apenas do administrador do fundo a observância dos limites por emissor e por modalidade de ativo financeiro, quando é o gestor que, primeiramente, compra e vende tais ativos. Neste sentido, o gestor é o responsável inicial pela escolha de tais ativos. Assim, entendendo que a obrigação de observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto do fundo de investimentos é comum a ambos. Dessa forma, não procede o argumento trazido pela Defesa*”.

¹⁹ Art. 56. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados, direta ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do fundo.

§1º - O administrador poderá contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e autorizados, os seguintes serviços, com a exclusão de quaisquer outros não listados:

I – a gestão da carteira do fundo; (...)

§2º - Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para:

I – negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo; e

II – exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto na política de voto do fundo.

²⁰ Art. 7º - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários somente é concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que: (...)

II – atribua a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários a um diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente autorizado a exercer a atividade pela CVM; (...)

Art. 21-A. O disposto nos artigos 14 a 16 desta Instrução aplica-se às atividade de administração e de gestão de fundos de investimento registrados na CVM.

²¹ Art. 13. Os cotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor, se houver, em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nesta Instrução.

²² Art. 63. Sem prejuízo das responsabilidades de cada um dos prestadores de serviços de administração do fundo, podem ser constituídos, por iniciativa dos cotistas, do administrador ou do gestor, conselhos consultivos, comitês técnicos ou de investimentos, os quais não podem ser remunerados às expensas do fundo. (...)

§2º A existência de conselhos não exime o administrador ou o gestor da responsabilidade sobre as operações da carteira do fundo.

²³ A área técnica justifica sua postura por entender que “[s]eria demasiado exigir que uma instituição administradora de fundos de investimento conferisse previamente junto ao emissor a autenticidade de um título, tarefa que, por certo, cabe ao gestor do fundo” e que “[a]lém disso, quando apresentou as notas e as boletas à BNY MELLON em 18.01.2012 (fls. 413/415), as operações já haviam sido executadas pela ATLÂNTICA no exterior, em que pese determinação da BNY de que qualquer operação realizada pelo BRASIL SOVEREIGN II deveria ser precedida de prévia análise e aprovação do administrador” (fl. 1176)

²⁴ Nesse sentido, atualmente, o §2º do art. 79 da ICVM 555 prevê inclusive a obrigatoriedade de cláusula impondo a responsabilidade solidária entre administradora e contratadas, sem que venha a afetar a responsabilidade administrativa de cada uma.

²⁵ Conforme se verifica da Ficha Cadastral Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Acusado possui participação direta de 95% do capital da sociedade, sendo que os 5% remanescentes pertenciam à L'Etoile Consultoria Ltda., da qual Fabrizio também era o representante (fl. 24).

²⁶ Fabrizio ainda alegou que o POSTALIS teria intervindo diretamente na referida operação. Entretanto, além de não haver nos autos qualquer prova de que o POSTALIS tenha influenciado na decisão das operações relatadas, uma eventual interferência do cotista, mesmo único, não exime o gestor de suas responsabilidades fiduciárias e de desempenhar suas atividades de forma independente, conforme posição já adotada no Processo Administrativo SEI nº 19957.002943/2016-71, deliberado na reunião do Colegiado de 08.11.2016, do qual fui relator.

²⁷ “No mérito, o acusado, em consonância com o já explicado em manifestação anterior, **reafirma que as operações em tela não foram por ele determinadas.** (...) Em verdade, conforme consta dos autos, conquanto a Atlântica fosse gestora das posições do Fundo de Investimento, desde maio de 2011, seus poderes já haviam lhe sido cassados” (sic) (fls. 1.215/1.216) (g.n.);

“Evidencia-se, pois, que nada indica que a ordem para adquirir as notas do UBS tenha sido dada pela Atlântica. Antes pelo contrário. **Não foi a Atlântica que determinou a realização dessa operação.** Repita-se: nada, não há nada – nem mesmo indícios – nos autos que vinculem Fabrizio Dulcetti Neves a essa operação, a esses termsheet, a liquidação da operação, etc.” (sic) (fl. 1236) (g.n.);

“Quem quer que tenha feito a operação, e, destaque-se, **esse alguém não foi Fabrizio Dulcetti Neves**” (grifo no original).

²⁸ O fato de o pagamento de US\$120.412.500,00 pelas *Credit Linked-Notes* da UBS estar fora das condições normais de mercado, além de incontroverso, constitui uma obviedade, posto que não é crível que se precificasse uma nota composta de títulos de dívidas do Brasil, Argentina, Venezuela e da PDVSA, em 2011, por montantes variando de 82% a 90% dos seus valores nominais, especialmente se consideradas as probabilidades de *default* de cada um dos títulos subjacentes, como estava claramente alertado nos *termsheets*.

²⁹ Art. 56, §2º, I, da ICVM 409/04: (...)

§2º - Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para:

I – negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo; (...)

³⁰ O Bank of Butterfield, como subcustodiante, provavelmente estaria “representando” algum investidor que não está indicado no presente processo, circunstância que não afeta a higidez da acusação, posto que a infração em discussão independe da contraparte da operação.

³¹ Cumpre ressaltar que a Euroclear, conforme previsto no regulamento do Fundo, que reproduziu regra da Regulação da CVM, era central depositária responsável pela compensação e liquidação das operações com os títulos da dívida externa da União, como se pode verificar no art. 8º, parágrafo primeiro, do Regulamento do Fundo (que, aliás, reproduz a redação idêntica do art. 96, §1º, da ICVM 409/04):

Parágrafo primeiro – Os títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União devem ser mantidos, no exterior, em conta de custódia, no sistema *Euroclear* ou *LuxClear* – *Central Securities Depository of Luxembourg CEDEL*)

³² Relatório de inspeção (no âmbito do Processo CVM nº RJ2010/7309) trazido aos autos confirma que Priscilla era funcionária da Atlântica: “Nessa data, com intuito de esclarecer pontos importantes para a conclusão do trabalho (...) comparecemos à sede da gestora (...) sendo recebidos por **Priscilla Moreira, Back-Office da empresa** (...)” (g.n.) (fls. 433).

³³ Mesmo domínio do e-mail de contato registrado por Fabrizio em seu cadastro na CVM como Prestador de Serviços de Administração de Carteiras e como responsável pela Atlântica Administração de Recursos Ltda., direto@atlanticaasset.com.br (fls. 27).

³⁴ “Diz-se que estão sendo enviadas as Notas. É o que diz o Termo de Acusação acima transcrito. Isto é, as Notas estariam em anexo. Não é, porém, o que diz o e-mail. Lá se diz ‘Term sheet das NP’. NP, o que seria NP? Porém, admitindo-se que fossem os term sheets, o que o BNY Mellon diz que consta do anexo do email são Minutas para discussão. Seria crível que o BNY Mellon tivesse contabilizado ativos de mais de US\$ 100 milhões, mediante uma minuta de dois Term Sheets. Ora, faça-me o favor. Esta é a coisa mais inverossímil do mundo. Nenhuma instituição financeira, por mais precária que fosse, teria contabilizado um papel, repita-se, de valor de mais de US\$ 100 milhões, com a remessa de uma minuta” (sic) (fls. 1.235).

³⁵ Conforme voto da Diretora Ana Novaes proferido no PAS nº 30/2005 (julgado em 11.12.2012) : “A questão que se coloca aqui é: quem está em erro? Até aqui, esta Autarquia entendia que se o operador/gerente do fundo de pensão participava do artifício (“esquema”), não se considerava que o fundo de pensão estivesse em erro.

Segundo o Diretor Roberto Tadeu, em um caso como este, quem está em erro não é o colaborador, gerente, ou dirigente do fundo de pensão, mas, sim, o trabalhador contribuinte daquele fundo de pensão. Isto significa que, dependendo do artifício utilizado, o operador/gerente do fundo de pensão pode ser responsabilizado tanto por prática não equitativa quanto por operação fraudulenta. Não será mais necessário presumir que o operador/gerente do fundo também estivesse em erro. Na prática, muitas vezes se verifica que é este operador/gerente justamente o pivô do “esquema”, tal como bem demonstrado neste PAS” (g.n.).

³⁶ Observe-se que, nessas boletas, há “erro material” quando ao ano no espaço “trade date”, mas, não há dúvida de que essas operações ocorreram em 2011, tanto que no espaço “settlement date” das mesmas boletas já há as indicações corretas do ano de 2011, mais precisamente 09.12.2011, que é exatamente três dias após o “trade date” (D+3). Além disso, o extrato de movimentação financeira junto à corretora *Tillerman Securities Ltd.*, às folhas 328, confirma a entrada de valores resultantes das operações em dezembro de 2011 (06.12.2011).

³⁷ Conforme comprovam as Boletas Euroclear de negociação (fls. 416/417) e o extrato de movimentação financeira junto à corretora *Tillerman Securities Ltd.*, às folhas 328 (nesse extrato, o referido valor é resultado da soma dos valores nominais dos títulos mais os juros recebidos).

³⁸ Tal posicionamento é compartilhado pela PFE-CVM no presente processo, que, no DESPACHO nº00104/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, o qual complementou o PARECER nº 00087/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, afirmou que (fls. 465): “Com efeito, e pelo exposto, para os fins de uma efetiva atuação sancionadora da Autarquia em casos envolvendo a prática de operação fraudulenta no mercado de valores

mobiliários, a discussão sobre se determinado valor foi efetivamente apropriado por esta ou por aquela pessoa, para fins de prova da intenção do acusado de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros, conforme consta do parágrafo 54 do termo de acusação, parece de todo desnecessária.”(g.n.)

³⁹ Além disso, a prática de ardil e a intenção de obtenção de vantagem não podem ser dissociadas, tanto que se utiliza do ardil justamente para obter o benefício indevido, e não de maneira involuntária e irrefletida.

⁴⁰ Sobre o efeito dissuasório da multa, que pressupõe obrigatoria e necessariamente a devolução de montante superior ao benefício auferido, cumpre transcrever a posição da Conselheira do Cade Cristina Alkmin J. Schmidt, que, em recente artigo publicado no Jornal Valor Econômico, afirmou o seguinte: “Neste sentido, um dos temas que mais está na pauta do dia é a discussão acerca de como o Cade deve punir. Uns entendem que deve ser de acordo com parâmetros exógenos. Outros, em que me incluo, que deve ser proporcional ao dano que o agente causou à sociedade, que, por sua vez, deve ser sempre acima da vantagem que este auferiu indevidamente por ter praticado a conduta anti competitiva” Jornal Valor Econômico de 14.08.17, pág. A12.

⁴¹ Para ser mais preciso, entre 28.11.2011 (emissão da 1ª nota) e 20.12.2011 (aquisições pelo Fundo).

⁴² Quando ao conluio entre o Acusado e esse terceiro que operou por intermédio do subcustodiante *Bank of Butterfield*, não tenho dúvida de sua existência, uma vez que, se assim não fosse, não haveria porque o Acusado enviar à Administradora um documento adulterado, indicando valor superior ao real, com o intuito de obstar a detecção da fraude.

⁴³ Fechamento Ptax = a partir de 1.7.2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3.506, de 23.9.10, e 3.537, de 25.5.11. Fonte: www.bcb.gov.br.

⁴⁴ Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei das Sociedades por Ações, das suas Resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...)

II - multa; (...)

Art. 11, §1º - A multa não excederá o maior destes valores: (...)

III - três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito. (Redação vigente à época)